

1500793-42.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas. 9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-

3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500793-42.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2147143/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 25280443 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2147143 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO ANDRADE GONÇALVES

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 21 dias do mês de setembro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e a Defensora Pública, Dra. Daniela Batalha Trettel. Apresentados o acusado RODRIGO ANDRADE GONÇALVES e as testemunhas arroladas em comum pelas partes Glauco Ageu da Silva e Luis Fernando Gomes da Silva.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do acusado com sua defensora, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao acusado a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos os depoimentos das testemunhas (Glauco e Luis Fernando) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado o réu.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:
Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:
"MM. Juíza,

RODRIGO ANDRADE GONÇALVES está sendo processado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 30 de maio de 2022, por volta de 18h45min., na rua Professora Lourdes Schmidt Furlan, nº 288, bairro Novo Horizonte, nesta cidade e comarca, trazia consigo "02 porções de "crack", 07 porções de "maconha" e 46 porções de "cocaína", destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente.

A materialidade foi comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 11), fotografia (fls. 12) e laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 92/94).

A autoria, da mesma forma, é indubitosa.

DOS FATOS

Segundo se apurou, guardas civis passavam pelo local, quando avistaram e suspeitaram do denunciado, que ao perceber a aproximação da viatura jogou um pacote que carregava nas mãos, tentando ocultá-lo".

Feita abordagem de praxe, em poder do denunciado foram localizadas sete porções de maconha e a quantia de R\$ 328,00 em notas diversas. No pacote dispensado por ele foram localizados quarenta e seis tubos de cocaína. Na sequência em revista realizada na delegacia de polícia, os guardas localizaram mais duas porções de "crack" no cós da bermuda do denunciado.

Informalmente, o denunciado alegou que é usuário de entorpecentes e praticava o crime para manter o vício. Perante a autoridade policial, ele permaneceu em silêncio.

As circunstâncias apuradas, local da prisão e apreensão de quantidade e variedade de droga e de dinheiro evidenciam que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

Com efeito, a testemunha Glauco Ageu da Silva, guarda municipal, disse em solo policial que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram um indivíduo andando pela via, sozinho, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, jogou um pacote que carregava na mão, na tentativa de ocultá-lo. Os guardas desconfiaram da atitude e realizaram a abordagem. Feita a revista pessoal, no bolso da blusa do indivíduo foi localizada uma pequena bolsa, dentro da qual havia dinheiro e sete porções de substância aparentando ser maconha. No pacote dispensado pelo sujeito foram encontradas quarenta e seis porções de cocaína. Disse que o acusado afirmou ser usuário de drogas e que realizava o tráfico para sustentar seu vício. Na Delegacia de Polícia, em nova revista pessoal, foram encontradas mais duas porções de "crack" com o acusado, localizadas no cós do seu short (fls. 02).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo guarda municipal Luís Fernando Gomes da Silva (fls. 03).

Em juízo, os guardas reafirmaram o que haviam declarado. Que o réu caminhava sozinho e dispensou um objeto ao ver a viatura, o que ensejou a abordagem.

Encontrou uma bolsa com ele com drogas. O objeto dispensado continha outras porções. Era uma embalagem plástica transparente e foi possível ver que continha pinhos de cocaína. Ele se disse usuário e traficar drogas para sustentar o vício. O local da abordagem é ponto de venda de drogas. Na Delegacia, mais porções foram encontradas com o réu em minuciosa revista. Tinham ido atender um disparo de alarme em uma escola e estavam voltando em direção ao posto de saúde, sendo que no trajeto deparou-se com o réu. Isso foi falado na Delegacia de Polícia, mas o escrivão entra

em minúcias. Abordaram o réu porque entendeu ele estar em flagrante delito. Era por volta de 19h00 quando da abordagem, mas estava claro pela luz do poste. Em solo policial e na fase judicial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 04/05). Diante do todo apurado há provas suficientes que demonstram que o réu foi autor do delito em questão.

A narrativa dos guardas foi firme e uníssona em confirmar que realizavam patrulhamento pelo local dos fatos e avistaram um indivíduo caminhando sozinho pela via e que, ao perceber a aproximação da viatura, jogou um pacote que carregava na mão. Desconfiados da atitude, realizaram a abordagem e a revista pessoal, sendo localizado no bolso da blusa do indivíduo uma pequena bolsa, dentro da qual havia dinheiro e sete porções de maconha. O pacote dispensado foi localizado e dentro dele havia quarenta e seis porções de cocaína. Aos guardas, o réu disse ser usuário de drogas e que realizava o tráfico para sustentar seu vício. Na Delegacia de Polícia, em nova revista pessoal, foram encontradas mais duas porções de "crack" com o acusado, localizadas no cós do seu short.

Diante da quantidade e da variedade dos entorpecentes apreendidos, resta claro que se destinavam à mercancia ilícita.

Pertinente salientar que não há nada que invalide os depoimentos dos guardas municipais, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso Salienta-se que a versão apresentada pelo denunciado não afasta o acerto do decreto condenatório. O fato de afirmar ser usuário de drogas não afasta a prática do crime de tráfico de entorpecentes, pois é comum a prática da comercialização ilícita para o fim de sustentar o próprio consumo.

Destarte, diante do conjunto probatório, imperiosa a condenação do réu pelo delito em questão.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

Réu primário.

Inaplicável o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois o réu responde a outro processo pelo mesmo crime (autos nº 1500731-02.2022.8.26.0599), cometido apenas 12 (doze) dias antes de ser novamente detido. Nesse sentido, RODRIGO foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas no dia 18/05/2022 e a ele foi concedida liberdade provisória; de volta às ruas, voltou a comercializar drogas no mesmo bairro e novamente foi preso em flagrante no dia 30/05/2022.

Sendo certa a condenação, o regime inicial deve ser o fechado diante da gravidade concreta do delito, único suficiente para repressão e reprovação dos delitos, além do fato de ser o réu contumaz na prática deste tipo de crime. Oportuno destacar ser vedada a conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (artigo 44 da Lei nº 11.343/06).

Presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, notadamente garantia da ordem pública, deverá ser indeferido apelo em liberdade.

Requeiro, por fim, seja decretado o perdimento do valor apreendido com o acusado, consistente em R\$ 328,00 reais (trezentos e vinte e oito reais), com fulcro nos artigos 62, §2º, e 63, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, requeiro seja julgada procedente a ação penal e o réu condenado nos exatos termos da inicial.

Dada a palavra à nobre defensora do acusado, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Rodrigo Andrade Gonçalves está sendo denunciado com incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls.61-66), no dia 30 de maio de 2022, por volta de 18h45, na rua Professora Lourdes Schmidt Furan, nº 288, bairro Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Piracicaba, Rodrigo trazia consigo 02 porções de "crack", 07 porções de "maconha" e 46 porções de "cocaína", destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

Ainda conforme a inicial acusatória, guardas civis passavam pelo local dos fatos, quando avistaram e suspeitaram do denunciado, que ao perceber a aproximação da viatura "jogou um pacote que carregava nas mãos, tentando ocultá-lo". Feita abordagem de praxe, em poder do denunciado foram localizadas sete porções de maconha e a quantia de R\$ 328,00 em notas diversas. No pacote dispensado por ele foram localizados quarenta e seis tubos de cocaína. Na sequência, em revista realizada na delegacia de polícia, os guardas localizaram mais duas porções de "crack" no cós da bermuda do denunciado. Informalmente, o denunciado alegou que é usuário de entorpecentes e praticava o crime para manter o vício.

Na delegacia, o guarda municipal Glauco Ageu Da Silva disse que: "Estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos em conjunto com seu parceiro de farda. O guarda afirma que, em determinado momento, avistou um indivíduo andando pela via, sozinho. O guarda afirma que, ao visualizar a aproximação da viatura, o indivíduo em tela, identificado posteriormente como o indiciado, jogou um pacote que carregava na mão, tentando ocultá-lo. O guarda desconfiou da situação e resolveu realizar a abordagem. Segundo o guarda, após revista pessoal, no bolso da blusa do indiciado foi localizada uma bolsa, dentro da qual havia dinheiro em espécie e sete porções de substância aparentando ser maconha. O guarda afirma que o pacote dispensado pelo implicado tratava-se de quarenta e seis porções de cocaína. O guarda afirma que, de maneira informal, o indiciado se disse usuário de drogas e realizava o tráfico para sustentar seu vício. O guarda afirma que, em revista pessoal na delegacia, foram localizadas mais duas porções de crack com o indiciado, no cós do seu shorts"(Fls.2).

No mesmo sentido as declarações do guarda municipal Luis Fernando Gomes da Silva (fls.3)

Interrogado em solo policial, Rodrigo exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 4-5).

Juntadas folha de antecedentes e certidões de objeto e pé (fls. 31-32) que comprovam a primariedade do acusado.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo laudo de fls. 92-94.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

Ouvido o guarda municipal Glauco Ageu Da Silva disse que estavam retornando de um atendimento de disparo de alarme em uma escola. Viram o réu caminhando e ele soltou uma embalagem plástica. Dentro da embalagem haveria pinos de cocaína, que a equipe disse que viu. Resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, em uma bolsinha, encontraram 328,00, em notas diversas, e 7 porções de maconha. Quanto aos pinos de cocaína, seriam 46. Não conhecia o réu. O local em que o réu estava é ponto de venda de drogas. Acha que foram localizadas porções de crack na roupa do réu na delegacia, mas não se recorda a quantidade. Perguntado para onde estavam se deslocando, disse que iam a um posto de saúde e vinham de uma escola. Perguntado o motivo de ter dito na delegacia que estava em policiamento ostensivo, disse que estava em "patrulhamento preventivo". Perguntado se a GCM foi orientada em razão da nova jurisprudência do STJ, segundo a qual somente pode atuar se estiver em área de equipamentos municipais, disse que sim, e que no seu entendimento estava atuando em um caso de flagrante. perguntado porquê não disse na delegacia que viu os pinos de cocaína na embalagem, disse que viu, que a embalagem era transparente, e que mesmo estando em um carro e sendo início da noite, garantiu que viu por conta da luz da rua. Perguntado o motivo de ter mudado a sua versão em relação à delegacia, disse que deve ter sido o escrivão.

Ouvido, em seguida, o guarda municipal Luis Fernando Gomes da Silva. Trouxe aos autos as mesmas informações do companheiro de farda.

Interrogado o acusado Rodrigo Andrade Gonçalves disse que trabalha como servente,

ganha R\$100,00/dia, e também recebe a pensão por morte do seu pai (R\$850,00). O dinheiro que estava carregando foi emprestado pela tia, o que faz habitualmente – quando recebe a pensão por morte do pai, no dia 5, devolve o dinheiro emprestado à tia. No mais, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio. É usuário de maconha, crack e cocaína. Disse que consegue ficar sem usar.

- DA ILICITUDE PROBATÓRIA: INCONSTITUCIONAL E ILEGAL ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Inicialmente, deve ser reconhecida a ilicitude probatória, tendo em vista a atuação inconstitucional e ilegal da Guarda Municipal.

A GCM se encontrava em evidente atividade de policiamento ostensivo e investigativo, fato que, por si só, é ilícita. Não bastasse, realizou investigação e revistas pessoal e do local, por suspeitar da atitude do réu.

Dessa maneira, a busca pessoal que resultou na apreensão das drogas foi oriunda de atuação da Guarda Civil Municipal. Ocorre que, nos termos da Constituição Federal, art. 144, § 8º, a Guarda Municipal não tem competência para tanto. É no mesmo sentido a lição doutrinária (GASPARINI, Diógenes; As guardas municipais na constituição federal de 1988, Revista dos Tribunais. set./1991. v.671 p. 46-53; SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição, 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 638-9).

Por conseguinte, é inafastável a conclusão de que a apreensão dos entorpecentes, por guardas municipais, é medida ilícita, tornando imprestáveis, portanto, os elementos de prova daí decorrentes.

Em reforço, não há que se alegar que os guardas municipais teriam atuado legitimamente porquanto, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, seria facultado a qualquer do povo efetuar a prisão em flagrante. In casu, não há que se falar em flagrante porquanto não houve qualquer motivação legítima para proceder à abordagem, eis que, conforme relatado pelos guardas municipais, logo após a visualização do imputado, eles efetuaram a abordagem em razão de “atitude suspeita”; o averiguado, portanto, não estava em situação de flagrância. Não é crível a mudança do depoimento dos guardas, depois de mudanças jurisprudenciais, sendo certo que o guarda Glaucio assumiu que os guardas foram orientados. Nesse ponto, cabe ressaltar que em toda a Comarca, repentinamente, todos os guardas passaram a dizer que estavam se deslocando de um equipamento municipal a outro. Na mesma senda, começaram a mudar versões para dizer que avistaram a droga de imediato, antes da abordagem.

E, ainda que superado esse argumento, considerando-se legítima a prisão em flagrante, é certo que os guardas municipais carecem de competência para efetuar a busca pessoal, atividade típica de policiamento, vez que esta não é um desdobramento automático e necessário do flagrante. Tanto que a prisão em flagrante e a busca e apreensão são disciplinadas em seções autônomas do Código de Processo Penal, sendo que a busca pessoal somente será realizada quando houver “fundada suspeita” (CPP, art. 240, § 1º); enquanto a busca pessoal é uma medida de obtenção de prova, a prisão em flagrante é um ato pré-cautelar.

Ademais, o art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem que a busca pessoal será conduzida pela autoridade policial. Assim, ainda que as guardas municipais, em razão do disposto no art. 144 da Constituição Federal, integrem a segurança pública, é certo que não podem ser considerados “autoridades policiais”; não por outra razão, quando efetuam a prisão em flagrante, fazem-no como “qualquer do povo”, com fundamento na parte inicial do art. 301 do Código de Processo Penal. Logo, para fins do art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, os guardas municipais não se equiparam às autoridades policiais. Assim, deparando-se com uma hipótese de flagrante, os guardas municipais devem apenas efetuar a custódia do indivíduo, encaminhando-o às autoridades policiais, sendo-lhes defeso efetuar a revista pessoal do cidadão detido.

Em síntese, atuando como “qualquer do povo”, os guardas municipais podem, única e exclusivamente, efetuar a custódia de algum cidadão que esteja em situação de flagrante (CPP, art. 301), mas não podem efetuar a busca pessoal ou desenvolver atividades tendentes à obtenção de elementos de informação, sob pena de afronta ao disposto no art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, eis que,

para esses fins, a despeito de estarem encarregados da segurança pública (CF, art. 144), não são considerados “autoridades policiais”. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (STJ, Habeas corpus 545.162/SP, Rel. Nefi Cordeiro, julgado em 4/2/2020).

Tal entendimento foi reforçado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Conforme a decisão, somente em situações absolutamente excepcionais, a guarda pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, devendo demonstrar que a ação está diretamente relacionada à finalidade da corporação:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras “polícias municipais”, mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte – apesar das investidas em contrário – por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal. 2. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil – em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência – estão sujeitas a rígido controle correccional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais – apesar da sua relevância – não estão sujeitas a nenhum controle correccional externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário. É de se ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal. 3. Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar – em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais – o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros. 4. A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para “Polícia Municipal”. Ademais, inúmeros municípios pelo país afora – alguns até mesmo de porte bastante diminuto – estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas. 5. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito. 6. Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de

flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes. 7. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. 8. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas. 9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais – e por isso interpretadas restritivamente – nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária. 10. Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito. 11. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese. 12. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1977119 - SP (2021/0391446-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Julgado em 16/08/2022. DJE 23/08/2022. Grifos nossos).

Assim, tem-se que a apreensão das drogas, no caso sub examine, é elemento de prova ilícito, tendo em vista a inconstitucional atuação da Guarda Municipal. Por esse motivo, o auto de apreensão das drogas deverá ser desentranhado dos autos, eis que é inadmissível o seu ingresso no processo (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157). E, por via de consequência, o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico são provas ilícitas por derivação, não podendo servir para formação da

convicção judicial, vale dizer, mostram-se incapazes para atestar a materialidade do delito imputado ao denunciado.

Desse modo, a absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP, é medida que se impõe.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

No mais, ainda que se entenda pela licitude da prova, o caso é de improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Eventual sentença de condenação estaria embasada nas declarações dos guardas municipais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. No caso concreto, os guardas mudaram partes importantes dos seus depoimentos, evidentemente adequando-os à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se mais preocupados com a adequação dos fatos às exigências legais para que possam licitamente atuar do que com a reprodução da verdade. Ademais, o acusado disse-se usuário de drogas (maconha, crack e cocaína), e a droga efetivamente localizada em seu poder – 2 porções de crack e 7 de maconha – são condizentes com o uso de entorpecentes, e não com o tráfico.

Além disso, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos guardas; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil.

Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA DESCLASSIFICAÇÃO: INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

No mais, ainda que se entenda pela suficiência probatória, impõe-se reconhecer que os elementos de prova produzidos em juízo não são suficientes para a constatação do delito de tráfico de drogas, mas, sim, para a configuração do uso de entorpecentes (LD, art. 28), uma vez que não demonstrado, de maneira inequívoca, o intuito de comercialização da droga.

O acusado disse-se usuário de drogas (maconha, crack e cocaína), e a droga efetivamente localizada em seu poder – 2 porções de crack e 7 de maconha – são condizentes com o uso de entorpecentes, e não com o tráfico.

Nessa linha de raciocínio, em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Autos da Revisão Criminal n. 0025831-60.2017.8.26.0000, valendo-se de pesquisas científicas efetuadas para diferenciar o traficante do usuário, rescindiu condenação proferida pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, entendendo que os fatos estariam melhor enquadrados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nas palavras da Eminente Relatora, “No tocante à quantidade, creio ser importante verificar pesquisas científicas sobre o tema e o ‘Estudo Técnico para Sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei 11.343/2006’, de autoria de Maria Tereza Uille Gomes, de 2014, disponível em www.politicassobredrogas.pr.gov.br, traz valiosas informações de pesquisas científicas realizadas no Brasil. Vejamos: ‘Estudo realizado através de pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, constatou que os pacientes viciados em cocaína utilizavam diariamente esta espécie de droga, na forma de sal, em variação

de 1 a 10 (um a dez) gramas/dia, com média de 3,8 gramas por dia (ACN Nassif Filho, SG Bettega, S Lunedo, JE Maestri, F Gortz- Repercussões otorrinolaringológicas do abuso de cocaína e/ou crack em dependentes de drogas. Revista da Associação Médica Brasileira, 1999; 45(3): 237-41). Segundo o IC/PR, a médica de uso de cocaína, na forma de crack, é de 15 pedras diárias e de acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack realizada por meio da parceria entre SENAD/MJ e a Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ é de 11 até 16 pedras diárias. A referida pesquisa destaca, no entanto, que não há como definir de forma minimamente precisa o peso em gramas e o conteúdo do que cada usuário denomina 'pedra'. Desse modo, há uma subjetividade intrínseca às definições utilizadas pelos próprios usuários. Inobstante a ressalva feita pela pesquisa, a informação técnica nº 023/2-13 SETEC/SR/DPF/RS

(Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do RGS), constata que cada pedra de crack pode variar de 01 a 1,5 gramas. Segundo o estudo realizado na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, a quantidade consumida por usuários de crack variava entre 1 a 15 gramas diárias, sendo que a média identificada foi de uso de 5,2 gramas por dia'. Ainda, no trabalho "Usuário de drogas ilícitas internados em hospitais psiquiátricos: padrões de uso e aspectos demográficos e epidemiológicos", de Paulo Borini e outros, publicado pelo Jornal Brasileiro de Psiquiatria, órgão oficial do IPUB Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do RJ, volume 52, mai/jun 2003, estudo realizado em um hospital psiquiátrico, informa que cerca de 51% são usuários de monodroga e 49% de polidroga. Indica que o consumo diário era igual ou menor de 15 (quinze) gramas de crack, 10 (dez) gramas de maconha e 5 (cinco) gramas de cocaína." (p. 8-9 do Acórdão)".

É justamente o caso narrado nestes autos, em que a quantidade de drogas apreendida do acusado não é excessiva, corroborando as declarações do acusado no sentido de que é usuário.

Isso posto, é necessário atentar-se ao fato de que a discricionariedade policial, consistente no poder de apontar se o indivíduo abordado é usuário ou traficante, deve ser contida em âmbito judicial. Como explica, a propósito, Luís Carlos Valois: "A possibilidade de aquele policial militar decidir, na esquina, se a pessoa abordada é usuária ou traficante de drogas é a mais grave das discricionariedades dessa guerra [guerra às drogas]. Do veredito das ruas poucos podem se livrar e, sacramentado o julgamento, seguirá o indiciado tendo que provar sua inocência com a grande dificuldade de um processo onde todas as testemunhas são policiais" (VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 28).

Por isso, para conter eventuais abusos e evitar injustas condenações, é necessário demonstrar, de maneira inequívoca, que as drogas apreendidas em poder do acusado se destinavam à comercialização, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não tendo sido demonstrado o intuito de comercialização da droga, impõe-se a desclassificação, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça:

"PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo do Ministério Público pela condenação por tráfico, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado o intuito de entrega do entorpecente a consumo de terceiros. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Desclassificação mantida. Apelo ministerial desprovido. Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o apelo defensivo" (TJ-SP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0001018-89.2017.8.26.0542, Rel. Diniz Fernando, julgado em 16/3/2020).

Com isso, resta configurada a conduta de uso de drogas, mostrando-se imperiosa a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. E, uma vez efetuada a desclassificação, exsurtem algumas consequências.

a) Absolução por inconstitucionalidade do tipo

A primeira delas é a necessária absolvição, tendo em vista a inconstitucionalidade do referido tipo. Com efeito, o art. 28 da Lei de Drogas é inconstitucional por ferir o disposto no art. 5º, X, da Constituição Federal. Isso porque é inquestionável que a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal afeta de modo desproporcional o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação, em suas diversas manifestações.

Nas palavras de Salo de Carvalho: "Os direitos à intimidade e à vida privada

instrumentalizam em nossa Constituição o postulado da secularização que garante a radical separação entre direito e moral. Neste aspecto, nenhuma norma penal criminalizadora será legítima se intervier nas opções pessoais ou se impuser padrões de comportamento que reforcem concepções morais. A secularização do direito e do processo penal, fruto da recepção constitucional dos valores do pluralismo, da tolerância e do respeito à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções indevidas na esfera da interioridade. Assim, está garantida ao sujeito a impossibilidade de plena resolução sobre os seus atos (autonomia) [...]” (CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 343-344). Adicionalmente, o art. 28 da Lei de Drogas ofende o princípio da lesividade. Ora, um dos preceitos básicos do Direito Penal é a alteridade da lesão, vale dizer, somente se pode criminalizar conduta que ofenda bem jurídico alheio. Como escreve, a propósito, Nilo Batista: “O mesmo fundamento veda a punibilidade da autolesão, ou seja, a conduta externa que, embora vulnerando formalmente um bem jurídico, não ultrapassa o âmbito do próprio autor, como por exemplo o suicídio, a automutilação e o uso de drogas. No Brasil, o art. 28 da Lei n. 11.343, de 23.ago.2006, que incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-criminais” (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 90).

Se é assim, tem-se que o consumo de drogas não ofende qualquer bem jurídico alheio, centrando-se na livre determinação do indivíduo que opta por fazer uso do entorpecente.

Desse modo, fixada tal premissa, é inquestionável que qualquer lesão potencial e suposta à saúde pública não pode ser utilizada para legitimar a intervenção penal no indivíduo. A título exemplificativo, o tabaco e o álcool ofereceriam lesividade, mas sua venda e consumo não são criminalizados. Para tais casos, é incontestável que o incremento de medidas restritivas de caráter administrativo, assim como políticas públicas de conscientização sobre o uso abusivo de tais substâncias se mostram eficazes. Logo, o mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação às demais drogas.

Anote-se, em reforço, que a criminalização do usuário tem o efeito perverso de rotulá-lo como marginalizado, o que dificulta a sua recuperação, especialmente em se tratando de jovens, que são o principal grupo consumidor de substâncias ilícitas. Isso posto, diante da alegação ora invocada, de rigor que seja declarada a inconstitucionalidade do tipo penal, em sede de controle difuso, afastando-se a imputação da conduta tipificada pelo art. 28 da Lei de Drogas, o que torna imperiosa a sua absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

b) Aplicação de sanção na forma do art. 28 da Lei de Drogas

Porém, rejeitada a pretensão de inconstitucionalidade, mas operada a desclassificação, é o caso de aplicação das sanções cominadas pelo art. 28 da Lei de Drogas.

- ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Pena-base

Na remota hipótese de condenação pela prática de tráfico de drogas, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior. Da mesma forma, o réu é primário e a quantidade de drogas não é exacerbada. Tais circunstâncias, portanto, recomendam a pena-base no patamar mínimo.

b) Segunda-fase: atenuantes

Ainda que aumentada a pena-base, é certo que o acusado é menor de 21 anos, motivo pelo qual faz jus à aplicação da atenuante do artigo 65, inciso I, do CP.

Da mesma forma, a confissão deve ser considerada (art. 65, III, d, CP).

Isso posto, a pena-base, se aumentada na primeira fase deve retornar ao mínimo legal.

c) Aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da LD

No presente caso, é possível o reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da LD. Ora, estão presentes todos os requisitos do referido dispositivo, sendo certo que,

conforme jurisprudência pacífica do STF, a quantidade e a natureza das drogas não é circunstância que, por si só, autoriza a denegação de aplicação do referido dispositivo (RHC 138715/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 23.5.2017).

Ainda, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível o afastamento do privilégio com base apenas na quantidade ou na qualidade da droga apreendida:

Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado e da redução da fração de diminuição de pena por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas. (STJ. 5ª Turma. REsp 1.985.297-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 29/03/2022. Informativo 731)

Por fim, imperioso ressaltar que, segundo a decisão sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), é vedado a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado. É o caso, portanto, de reconhecimento do privilégio, devendo a pena ser diminuída em seu grau máximo.

- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, reconhecido o privilégio, de rigor a fixação do regime inicial aberto.

Ainda que não aplicado o redutor do art. 33, §4º, da LD, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime semiaberto.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMO TEMPO DE PENA JÁ CUMPRIDO (DETRAÇÃO E ART. 387, § 2º, DO CPP)

Além disso, considerando que o réu respondeu preso ao processo, impõe-se que o tempo de prisão provisória seja declarado como tempo de pena já cumprida, efetuando-se, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, a detração; é o que se extrai do referido dispositivo, assim como da Exposição de Motivos da Lei n. 12.736/2012 e da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 652.915/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

- SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Finalmente, reconhecido o privilégio, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque o Senado Federal, no uso da atribuição que lhe confere o art. 52, X, da CF, editou a Resolução n. 05/2012, suspendendo a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A Resolução por conta do julgamento do Habeas Corpus 97.256/RS, em setembro de 2010, ocasião em que o STF, por seis votos a quatro, o STF decidiu que são inconstitucionais dispositivos da Lei n. 11.343/2006 que proíbem expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas. Ainda que se discorde da conclusão alcançada pelo STF, o fato é que, com a edição da mencionada Resolução, pelo Senado Federal, restou afastado o fundamento formal-positivo para a proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que suspensa a execução da lei, dotando a decisão do STF, tomada em sede de controle incidental, de efeitos erga omnes. Possível, pois, a aplicação de penas restritivas de direitos, porquanto presentes os requisitos do art. 44 do CP: a) a pena, ao final aplicada, não será superior a 4 anos; b) o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; c) o réu não é reincidente em crime doloso; d) a medida mostra-se suficiente, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59.

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. Com

efeito, de acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador “[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2). Em seguida pela MM.Juiza foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

RODRIGO ANDRADE GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 30 de maio de 2022, por volta de 18h45, na Rua Professora Lourdes Schmidt Furlan, nº 288, bairro Novo Horizonte, nesta cidade e comarca, trazia consigo 02 porções de “crack”, 07 porções de “maconha” e 46 porções de “cocaína”, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desarco com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas civis passavam pelo local, quando avistaram e suspeitaram do réu, que ao perceber a aproximação da viatura “jogou um pacote que carregava nas, tentando ocultá-lo”.

Feita abordagem de praxe, em poder do réu foram localizadas sete porções de maconha e a quantia de R\$ 328,00 em notas diversas. No pacote dispensado por ele foram localizados quarenta e seis tubos de cocaína. Na sequência em revista realizada na delegacia de polícia, os guardas localizaram mais duas porções de “crack” no cós da bermuda do réu.

Informalmente, o réu alegou que é usuário de entorpecentes e praticava o crime para manter o vício. Perante a autoridade policial, ele permaneceu em silêncio.

As circunstâncias apuradas, local da prisão e apreensão de quantidade e variedade de droga e de dinheiro evidenciam que a droga apreendida se destinava à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

A denúncia foi oferecida (fls. 64/66), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 68/69).

Notificado (fls. 75), o réu apresentou defesa prévia, na qual aduziu a inexistência de questões preliminares e informou que irá se manifestar sobre o mérito ao final da instrução processual, além de requerer a revogação da prisão preventiva com fixação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 79/82).

A denúncia foi recebida, mantendo-se a prisão do réu e designando-se audiência (fls. 95/97). O réu foi citado (fls. 114).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

I - Da preliminar

Arguiu a Defesa, que o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da prisão realizada por guardas municipais. Argumenta que houve diligência típica de atividade policial, não permitida aos guardas municipais.

Não há, contudo, qualquer nulidade na prisão em flagrante do réu.

A Lei nº 13.022/14 conferiu expressamente à Guarda Municipal a atribuição de polícia ostensiva, nos termos do artigo 3º da referida legislação, que assim dispõe: “Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força”.

De qualquer modo, nada obstante o disposto no artigo 144, parágrafo 8º, da

Constituição Federal, é certo que, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, não há uma proibição de que os guardas municipais prendam alguém em flagrante, haja vista que qualquer pessoa do povo também pode fazê-lo.

E, no caso concreto, ao contrário do postulado pela Defesa, o réu foi abordado na posse da droga, havendo flagrante, consoante prevê o artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Note-se que o patrulhamento que os guardas civis mencionaram, na fase policial, foi explicada em Juízo, como sendo patrulhamento entre uma escola e um posto de saúde municipal. Além disso, os guardas civis descreveram que passavam pelo local e avistaram o réu jogando o embrulho no solo e, como o saco era transparente, ambos indicaram que visualizaram que